

1502190-12.2021.8.26.0005

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional V - São Miguel Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... reincidência, referente ao crime de tráfico de entorpecentes - Gravidade do crime precedente que não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime intermediário bem fixado - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0009069-08.2016.8.26.0451; Relator (a): Rodrigo Pares Andreucci; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional V - São Miguel Paulista

2ª Vara Criminal

Av. Afonso Lopes de Baião nº 1736, São Paulo-SP - cep 08040-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502190-12.2021.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502190-12.2021.8.26.0005

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Contravenções Penais

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3054789/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 18829333 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

José Teixeira de Jesus Neto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA NISHINA DE AZEVEDO

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

As testemunhas ouvidas sob os rigores do contraditório declararam que o acusado mantinha várias máquinas caça niqueis no interior da padaria, em sala contígua, passando pelo banheiro. Havia máquinas ligadas e desligadas. Tanto a testemunha Lídio quanto a testemunha Carlos disseram que havia dinheiro guardado em local diverso das máquinas, mas que não viram relação com o maquinário ilícito. Na ocasião, o dono do estabelecimento lhes disse que mantinha as máquinas como forma de pagar as contas.

O acusado negou em parte a imputação. Disse que era dono da padaria havia dois meses, mas que jamais ligou as máquinas. Pediu para retirarem as máquinas, mas não disse a quem fez tal pedido. Negou ter auferido lucro das máquinas. Admitiu que as máquinas estavam no funda da padaria, porém cobertas por lonas.

A prova da tese acusatória é suficiente.

De início, acerca da legitimidade dos depoimentos dos agentes públicos que presenciaram os fatos aqui narrados. Há muito tempo a jurisprudência pôs fim a essa questão ao decidir que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se

evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma HC 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Nesse sentido, as declarações das testemunhas Lídio e Carlos são firmes e coesas, não deixando dúvida de que o acusado mantinha em seu comércio as máquinas caça-níqueis, em local acessível ao público.

A materialidade veio provada pela prova pericial (fls.48/60), que constatou que "as máquinas eletrônicas encontradas no interior do imóvel em referência são classificadas como "Máquina Sorteadora Aleatória de Resultados", onde o apostador não interfere no resultado, portanto, o ganho ou perda não dependem de sua habilidade física ou intelectual, ou seja, dependem única e exclusivamente da sorte, tratando-se, assim, de equipamento utilizado para a prática de jogo de azar."

Assim, da prova pericial, constata-se que as máquinas encontradas junto ao estabelecimento do réu possibilitavam a prática de jogo de azar, em que presente a álea como elemento determinante para o ganho ou a perda pelos jogadores. Não há, portanto, dúvida quanto à idoneidade do objeto para o fim contravencional.

Nesse sentido, pontua-se que a contravenção penal prevista no artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/1941 consiste na exploração de jogo de azar e não da propriedade da máquina. Dessa forma, a conduta descrita no tipo penal foi efetivamente praticada pelo acusado, já que permitiu a instalação de máquina destinada ao jogo de azar em seu estabelecimento.

No mais, na fl. 52, constatou-se que as máquinas estavam aptas ao funcionamento. Diante disso, observam-se demonstrados todos os elementos do tipo penal objeto da acusação, logrando-se comprovar que o réu estabeleceu jogo de azar, por permitir a instalação de máquinas caça-níqueis em funcionamento em seu estabelecimento, bar acessível ao público. Dispensável para a configuração da contravenção que houvesse apostadores ou a demonstração de efetivas apostas, bastando, como se provou no caso vertente, que estivessem máquinas programadas para jogo de azar acessíveis ao público.

Nesse sentido a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR (LCP, ART. 50, CAPUT). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS E NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU QUE TINHA EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL À DISPOSIÇÃO PARA JOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO". (Apelação Criminal nº 2009.040244-5, de Balneário Camboriú. Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco. J. 19.05.2011) grifo nosso

"APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAÇÃO PENAL. CAÇA NÍQUEL CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, CONFIRMANDO QUE O LOCAL ERA DESTINADO A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. APREENSÃO DE 21 (VINTE E UMA) MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEL E ELEVADA QUANTIA EM, DINHEIRO. PROVAS DEMONSTRANDO QUE, DE FATO, AS MÁQUINAS APREENDIDAS ESTAVAM EXPOSTAS E EM PLENO FUNCIONAMENTO, FAVORECENDO O JOGO ILÍCITO. LOCAL ACESSÍVEL AO PÚBLICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NOS TERMOS DA LEI PENAL E LEVANDO-SE EM CONTA A QUANTIDADE DE MÁQUINÁRIO APREENDIDO. APENADO QUE JÁ POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS. INVIÁVEL A CONVERSÃO DO REGIME A ELE APLICADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO LAVRADO PELA POLÍCIA MILITAR. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SUAS RAZÕES E FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO". (STF.RE 979730, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 01/08/2016)

Ressalte-se, ademais, que, foi apreendida quantia superior a R\$ 200,00 (duzentos reais) junto aos equipamentos. Não suficiente, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a contravenção penal descrita na demanda é delito de mera conduta, sendo irrelevante se as máquinas estavam desligadas ou desprovidas de numerários no momento em que apreendidas. Dessa forma, inexiste escusa defensiva apta a afastar a condenação.

Nesse sentido:

"Contravenção de Jogo de Azar (máquinas caça-níqueis) -Materialidade perfeitamente demonstrada - O laudo pericial de fls. 06/141 é claro em dizer que, nas máquinas apreendidas, o ganho independe da habilidade do jogador, caracterizando, pois, jogo de azar - Autoria bem demonstrada - Recorrente que admitiu ser o proprietário do bar e que as máquinas estavam em seu interior - Policial que confirmou a apreensão das máquinas em seu estabelecimento - Fato de as máquinas estarem desligadas que não implica em "ausência de exploração do jogo" - Manobra corriqueira para tentar se eximir da responsabilidade penal - Máquinas em local de acesso ao público e que, para serem manuseadas, bastaria ser ligada na tomada de energia - Recorrente que já se viu envolvido na mesma atividade em outras oportunidades, conhecedor, pois, das consequências da manutenção das máquinas no estabelecimento comercial - Pena que merece reparo - Maus antecedentes que não podem prosperar, eis que a condenação que deu causa ao reconhecimento da majorante transitou em julgado posteriormente aos fatos aqui tratados - Pena que é arbitrada inicialmente em três meses de prisão simples mais o pagamento de dez dias-multa - Reprimenda acrescida em um sexto pela reincidência do acusado (fls. 84), resultando em três meses e quinze dias de prisão simples, mais onze dias-multa - Regime intermediário bem fixado pela reincidência, referente ao crime de tráfico de entorpecentes - Gravidade do crime precedente que não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime intermediário bem fixado - Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0009069-08.2016.8.26.0451; Relator (a): Rodrigo Pares Andreucci; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/01/2021; Data de Registro: 19/01/2021) grifo nosso

APELAÇÃO CRIMINAL - JOGOS DE AZAR (ART. 50, DO DECRETO-LEI Nº 3.668/41. EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS - Sentença absolutória - Recurso ministerial - Pretendida condenação do acusado nos exatos termos da denúncia - Possibilidade - Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas - Confissão extrajudicial que vem amparada em outros elementos de convicção amealhados durante a instrução - Depoimento de policiais - Validade - Crime de mera conduta, sendo irrelevante que as máquinas estivessem desligadas e/ou sem dinheiro, já que tais condições não são exigidas pela lei, bastando apenas a destinação do equipamento ao jogo de azar - Sentença reformada - Condenação decretada - Pena fixada no mínimo legal, dada as circunstâncias judiciais favoráveis ao agente - Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos - Cabimento - Preenchimento dos requisitos legais exigidos no art. 44, do Código Penal. Prescrição - Ocorrência - Reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão punitiva estatal - Decurso do interstício temporal entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento - Sentença absolutória que não é considerada marco interruptivo do prazo prescricional - Recurso ministerial provido e decretação ex officio da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0008108-98.2011.8.26.0271; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/12/2015; Data de Registro: 18/12/2015) grifo nosso

"CRIMINAL - JOGO DE AZAR - ARTIGO 50 DO DECRETO-LEI 3.688/41 - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA DEMONSTRADA PELA ADMISSÃO DO RÉU DE QUE ERA A O PROPRIETÁRIO DO BAR E QUE LÁ HAVIA A MÁQUINA CAÇA-NÍQUEL APREENDIDA - POLICIAL CIVIL QUE FEZ A DILIGÊNCIA E TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA, QUE DISSE PRESTAR SERVIÇOS ESPORÁDICOS NO BAR, CONFIRMARAM A EXISTÊNCIA DA MÁQUINA NO ESTABELECIMENTO - POLICIAL ESCLARECEU QUE A MÁQUINA FICAVA NUM DEPÓSITO E QUE O LOCAL ERA ACESSÍVEL AOS CLIENTES - FATO QUE, POR SI SÓ, FAZ PRESUMIR A EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR PELO RÉU - INVEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO RÉU, PESSOA EXPERIENTE E QUE JÁ FOI CONDENADA DIVERSAS VEZES PELA MESMA INFRAÇÃO, DE QUE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO DEIXOU A MÁQUINA EM SEU ESTABELECIMENTO CONTRA SUA VONTADE - EVIDENTE QUE ELA FOI ALI COLOCADA PARA EXPLORAÇÃO DOS JOGOS DE AZAR PELO ACUSADO - IRRELEVANTE QUE, NO MOMENTO DA APREENSÃO, ELA ESTAVA DESLIGADA E SEM DINHEIRO - CONFORME ESCLARECEU O POLICIAL CIVIL, A AÇÃO POLICIAL FOI MOTIVADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA DA INFRAÇÃO NO LOCAL DOS FATOS E É MUITO COMUM, EM CASOS COMO ESSE, OS

INFRATORES MANTEREM AS MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS DESLIGADAS, LIGANDO-AS SOMENTE QUANDO SÃO USADAS PELOS JOGADORES, PODENDO, INCLUSIVE, SER USADA EXTENSÃO ELÉTRICA PARA QUE SEJA LIGADA EM TOMADA EXISTENTE EM CÔMODO ANEXO - MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO LAUDO PERICIAL DE FLS. 30/33, O QUAL FOI CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A MÁQUINA APREENDIDA APRESENTA-SE COMO SORTEADORA ALEATÓRIA DE RESULTADOS E O GANHO OU PERDA INDEPENDEM DE CAPACIDADE FÍSICA OU MENTAL DO AGENTE, O QUE BASTA PARA A COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR NO LOCAL - TIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, EIS QUE NÃO FOI CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO NA AÇÃO COM REPERCUSSÃO GERAL A RESPEITO DO TEMA A SER JULGADO PELO C. STF - CORRETA CONDENAÇÃO - RÉU PORTADOR DE PÉSSIMOS ANTECEDENTES (FLS. 44/48) E REINCENTE ESPECÍFICO (FLS. 46) - AUSÊNCIA DE ATENUANTES - PROBLEMAS DE SAÚDE DO RÉU NÃO CONSTITUEM ATENUANTES NEM CAUSAS DE ISENÇÃO DE PENA - PENA FIXADA EM 4 MESES E 2 DIAS DE PRISÃO SIMPLES E 13 DIAS-MULTA - PÉSSIMOS ANTECEDENTES E REINCENTE ESPECÍFICA IMPÕEM A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL E IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM" - RÉU NÃO ESTÁ PRESO POR ESTE PROCESSO, NÃO HAVENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER RECONHECIDO - QUESTÃO REFERENTE À VAGA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM REGIME FIXADO E EVENTUAL DIREITO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR EM RAZÃO DE PROBLEMA DE SAÚDE SÃO MATÉRIAS QUE CABEM AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA JUÍZA RELATORA" (TJSP; Apelação Criminal 1514297-16.2018.8.26.0451; Relator (a): Ana Claudia Madeira de Oliveira; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Piracicaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020) (grifo nosso)

Finalmente, as teses defensivas quanto às dificuldades econômicas do país não se prestam a fundar decreto de improcedência. Não há prova de estado de necessidade, até porque o acusado admitiu que tinha valores em dinheiro dentro do comércio para pagar suas contas. Irrelevante que o jogo de azar seja corriqueiro, pois há norma vigente expressa quanto à contravenção, a ninguém se escusando de sua observância. Não se vê hipótese de desconhecimento da lei, até porque o réu já foi condenado mais de uma vez pelo mesmo crime. Outrossim, a ninguém é dado deixar de cumprir o comando legal por desconhece-lo.

Passa-se, então, à dosimetria da pena.

Da análise dos antecedentes do acusado (fls. 18/35), verifica-se que o réu já sofreu quatro condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor.

A primeira oriunda do processo 0044157-92.2013, desta Vara Criminal, com trânsito em julgado em 30/05/2019 (fl. 34), pela prática da contravenção prevista no artigo 50, caput, da Lei 3688/1941. Trata-se de condenação com trânsito em julgado antes do fato que aqui se julga e com extinção da pena em intervalo inferior ao prazo do artigo 64, I, do CP. Tal condenação será tomada como reincidência, não se prestando a configurar mau antecedente para evitar dupla apenação pelo mesmo fato.

A segunda oriunda do processo 0004891-98.2013, da 01ª Vara Criminal deste Foro Regional, pela prática do crime previsto no artigo 50, §3, "a", da Lei 3688/1941, com trânsito em julgado em 10/03/2015 (fl. 33). Tal condenação não se presta a fundar reincidência e será tomada como mau antecedente, para evitar dupla apenação pelo mesmo fato.

A terceira decorrente do processo 0014683-96.2001 da 1ª Vara Criminal deste Foro Regional, pela prática do crime previsto no artigo 10, caput, da Lei 9437/97, com trânsito em julgado em 12/08/2005, data anterior ao fato que aqui se julga. Em se tratando de pena extinta há mais de cinco anos, tal condenação não se presta a fundar reincidência e será tomada como mau antecedente.

A quarta advinda do processo 0004016-53.2017, da 05ª Vara de Execuções Criminais, pela prática do crime previsto no artigo 289, §1º, do Código Penal, com trânsito em julgado em 18/04/2013 (fl. 34). Em se tratando de pena extinta há mais de cinco anos, tal condenação não se presta a fundar reincidência e será tomada como mau antecedente.

Assim, conclui-se que o acusado é indivíduo reincidente e que ostenta três maus

anteriores. Cada qual destes fatores fomentará o aumento de um sexto da pena. Nesse sentido, pontue-se o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593818, com repercussão geral, firmou o entendimento de que o prazo quinquenal de prescrição na reincidência não se aplica aos maus antecedentes. Confira-se:

"Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, haja vista a existência de três maus antecedentes pela contravenção de explorar jogos de azar. Cada mau antecedente enseja o aumento de 1/6 (um sexto), de forma que, ao cabo da primeira fase, aumenta-se a pena mínima da metade (1/2), que resta fixada em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, presente a agravante da reincidência, o que enseja o aumento de mais 1/6 (um sexto) da pena, que resta fixada em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de prisão simples e 17 (dezessete) dias multa.

Na terceira fase de aplicação da pena não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torna definitiva a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de prisão simples e 17 (dezessete) dias multa.

Não estão presentes os requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco para a suspensão condicional da pena, na forma dos artigos 44 e 77 do Código Penal, pois o réu é reincidente em crime doloso. O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, já que se trata de acusado reincidente, o que justifica a fixação de um regime de pena intermediário para efetiva prevenção e reparação do crime, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b" c.c artigo 59, ambos do Código Penal.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira do réu que autorizasse a majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, decido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório inicial para CONDENAR o réu José Texeira de Jesus Neto, inscrito no CPF/MF sob o n. 892.029.375-91, portador do RG n. 39.969.500/SSP/SP, filho de Ariosvaldo de Souza Teixeira e Dinaura de Jesus Teixeira, nascido em 04/04/1976, natural de Gentio do Ouro/BA, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial semi-aberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, por incurso no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais.

Considerando o montante da pena fixada, que não será cumprida em regime de máxima segregação. Reconheço o direito do réu de apelar em liberdade.

Determino, ademais, a destruição das máquinas apreendidas, caso tal medida ainda não tenha sido tomada. Oficie-se.

Sem custas na espécie, observando-se, ademais, que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, na medida em que assistido pela DPE e não demonstra gozar de posses incompatíveis com a pobreza.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em proveito do patrono dativo, no patamar máximo da tabela.

Ciência ao MP e à defesa. Intime-se o acusado por WhatsApp, conforme por ele consentido em audiência.

P.I.

São Paulo, 13 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA